

1500178-20.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... e autoria quanto à prática de tráfico de drogas pelos Réus, em concurso de pessoas, especialmente diante do relato coeso dos policiais militares; b) não há prova suficiente para a condenação por associação para o tráfico, de sorte que eles devem ser absolvidos; c) a pena-base, quanto ao tráfico, deve ficar acima do mínimo legal; d) o regime inicial deve ser o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500178-20.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-20.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035145/2021 - DEL.POL.LORENA, 16087399 - DEL.POL.LORENA, 130/21/204 - DEL.POL.LORENA, 2035145 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 130/21/204 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ANTUNES ORTIZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia em face de JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR e BRUNO ANTUNES ORTIZ pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343.06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

De acordo com a denúncia: no dia 5 de fevereiro de 2021, por volta das 22 horas e 14 minutos, na Travessa Rui Barbosa, n.º 4, Vila Carmem, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, e BRUNO ANTUNES ORTIZ, associaram-se para praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

Consta, ainda, que no mesmo contexto temporal e espacial supramencionado, JURACI

RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR e BRUNO ANTUNES ORTIZ, transportavam, guardavam e tinham em depósito, para fins de comércio a terceiros, 0,79g (setenta e nove centigramas) de cocaína, divididos em 4 (quatro) microtubos, bem como 10,86g (dez gramas e oitenta e seis centigramas) da mesma substância, divididas em 22 (vinte e dois) microtubos, substância esta entorpecente que causa dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização legal ou regulamentar.

Às fls. 77/78 houve homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva.

Às fls. 90/694 foi impetrado Habeas Corpus em favor dos réus.

Às fls. 129/131 foi determinada a nova prisão dos Réus.

Em 22 de Abril de 2021, houve o recebimento da denúncia (fls. 193/194).

Às fls. 44/46 e 176/178, foram juntados os laudos de constatação, evidenciando a presença de COCAÍNA.

Às fls. 211/221 foi confirmada a cassação da liminar dada anteriormente no HC, reestabelecendo a prisão preventiva.

Às fls. 229/231, JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR apresentou resposta à acusação.

Às fls. 237 e 265/272, BRUNO ANTUNES ORTIZ apresentou resposta à acusação.

Às fls. 299/301, designou-se audiência de instrução.

Em 04/02/2022 e 25/02/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a) há prova de materialidade e autoria quanto à prática de tráfico de drogas pelos Réus, em concurso de pessoas, especialmente diante do relato coeso dos policiais militares; b) não há prova suficiente para a condenação por associação para o tráfico, de sorte que eles devem ser absolvidos; c) a pena-base, quanto ao tráfico, deve ficar acima do mínimo legal; d) o regime inicial deve ser o fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

Em alegações finais, a defesa de JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR afirmou que: a) não há prova do dolo; b) não há indicação precisa sobre a conduta de cada um; c) deve haver a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; d) não há prova da materialidade nem da autoria do crime de tráfico de drogas; e) não é viável a condenação pelo crime de associação para o tráfico; f) em caso de condenação, a pena deve ficar no mínimo legal, com aplicação da redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; g) deve haver a conversão em penas restritivas de direitos;

Em alegações finais, a defesa de BRUNO ANTUNES ORTIZ afirmou que: a) não há prova de que a conduta se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas; b) as provas produzidas em juízo não confirmam a imputação; c) não há prova do dolo exigido pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas; d) não houve comprovação da autoria e da materialidade; e) deve haver a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; f) não é viável a condenação por associação para o tráfico; g) em caso de condenação pelo art. 33, caput, a pena deve ficar no mínimo legal, com aplicação do art. 33, §4º e regime inicial aberto, além da conversão em penas restritivas de direitos.

É o relatório.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Do crime do art. 33 da Lei de Drogas

Da regularidade da denúncia

Em suas alegações finais de fls. 365/387, o Réu JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR afirma que não houve identificação das condutas dos Réus na denúncia.

Da regularidade da denúncia

O art. 41 do CPP elenca os requisitos que devem constar numa denúncia:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com relação à narrativa dos fatos, o entendimento é de que a denúncia é regular

quando a imputação é feita de forma clara, com exposição das condutas imputadas ao Réu e suas circunstâncias:

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. A exordial acusatória preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (CPP, art. 41), porquanto qualificou os acusados e descreveu, de forma clara e pormenorizada, a infração penal a eles imputada, com todas as suas circunstâncias e elementares, apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo. Preliminar afastada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO.

INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prisão em flagrante da acusada Luciana, que trazia consigo 194,8g de maconha, ocultos em sua cavidade vaginal, em procedimento de revista prévio ao ingresso no estabelecimento prisional em que recluso o acusado Wesley, seu companheiro e destinatário da droga. Depoimentos das agentes de segurança penitenciária, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram seguros, coerentes e harmônicos, em consonância com os demais elementos de prova. Acusada Luciana que confessou a imputação, embora tenha afirmado que agiu sob ameaça de Wesley. Este acusado, de seu turno, afirmou que coagiu Luciana a praticar tal conduta. Versões que, embora contenham as elementares do tipo, não encontram respaldo no conjunto probatório, ao menos no que tange à delimitação das responsabilidades dos acusados. Não comprovada a relação lógica entre episódio pretérito de violência doméstica, que remete a 2014, e suposta coação moral irresistível com vistas à prática do ato em questão. Luciana mantinha relacionamento amoroso com Wesley e o visitava regularmente, desde que fora preso, em 2015. Testemunhas que não foram precisas quanto às supostas ameaças. Incumbe à defesa a prova da ocorrência da alegada coação moral irresistível, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 156 do C.P.P.). Em se tratando o tráfico de drogas de crime unissubsistente e permanente, não há que se falar em reconhecimento de meros atos preparatórios ou tentativa em relação a Wesley, que efetivamente concorreu para o crime em questão, em sua forma consumada. Não configuração de crime impossível. A mera existência de agentes penitenciários, vigilância, revista e outras formas de fiscalização em estabelecimento prisional não caracteriza ineficácia absoluta do meio empreendido para fazer ingressar drogas no local, já que aqueles recursos, embora eficientes, não são capazes de impedir toda e qualquer ação delitiva. Mantida a condenação dos acusados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem o vínculo associativo estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/06, conduz à absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória. PENAS. Ré Luciana. Base no mínimo legal, assim mantida ao final da segunda etapa. Apesar de Luciana ter confessado os elementos típicos do tráfico ilícito de entorpecentes, alegou uma causa de exclusão da culpabilidade, razão pela qual inviável o reconhecimento da atenuante. Negativa do redutor pelas circunstâncias do crime, considerada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (194,8g de maconha), que os acusados pretendiam introduzir em estabelecimento prisional, circunstâncias a indicar que não se trata a apelante de "traficante de primeira viagem", figura visada pela excepcional causa de diminuição de pena Mantido o acréscimo de 1/6 pela causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei Antidrogas. Penas mantidas. Réu Wesley. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, pela má antecedência e personalidade malformada. Afastamento da segunda circunstância, por ausência de elementos nos autos, com aumento das penas em 1/12. Na segunda etapa, reconhecimento, nesta Instância, da atenuante da confissão espontânea, compensada com a agravante da reincidência. Não era mesmo o caso de reconhecimento do privilégio, diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Mantido o acréscimo de 1/6 pela causa especial de aumento do art. 40, III, da Lei Antidrogas. Penas reduzidas. REGIME. Manutenção do regime inicial fechado. Quantum de penas superiores a quatro anos, gravidade concreta do delito diante da natureza e quantidade e de drogas, bem como das circunstâncias do crime em concreto, com vistas à prevenção delitiva e tutela social, ao menos no

início do cumprimento da pena, a par da reincidência e maus antecedentes de Wesley. BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal, tendo em conta a pena concretizada, além da insuficiência da repressão delitiva caso concedida qualquer dessas benesses, ao que se somam a reincidência e os maus antecedentes de Wesley. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, para fins de satisfação da pena. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal Recursos defensivos parcialmente providos para absolver Luciana e Wesley do crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como redimensionar as penas de Wesley, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, para 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 631 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP; Apelação Criminal 0000201-94.2017.8.26.0616; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Preliminar - Nulidade por inépcia da denúncia - Inocorrência - Peça acusatória que identifica e qualifica o acusado, bem como descreve com clareza as imputações, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa - Observância do art. 41 do CPP - Mérito - Pleito de absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas - Crime que nem sempre deixa vestígios - Prova oral que dá a certeza do cometimento do delito pelo acusado - Desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor - Descabimento -- 'Animus' do agente bem evidenciado. Ademais, os atos não se deram em ambiente público ou acessível ao público - Desistência voluntária - Inviabilidade - Crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente - Instituto incompatível com a tentativa reconhecida - Condenação mantida - Pena - Fração de redução pela tentativa já aplicada no máximo legal - Regime fechado único adequado à espécie, ante a gravidade concreta dos fatos - Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500611-19.2020.8.26.0537; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022) (grifos acrescidos)

No caso concreto, não se pode falar na inépcia da denúncia, uma vez que os fatos imputados são narrados com clareza, com indicação da conduta atribuída aos Réus (fls. 1/2, com indicação do local da abordagem, do que foi encontrado com cada um dos acusados e do que se apurou sobre a atuação de cada um deles). Desta forma, rejeito a tese defensiva.

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades vender, expor à venda e trazer consigo. Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo

condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 11 demonstra que foram apreendidos: a) R\$221,00 em espécie com BRUNO; b) 2 pinos de cocaína com BRUNO; c) 22 pinos de cocaína com JURACI.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 44/46, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 176/178, verificou-se que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se precisamente de cocaína, no total de 36,76g de massa líquida (fls. 44/46). Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que os acusados BRUNO ANTUNES ORTIZ e JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, agindo em concurso de pessoas, foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia. Ouvida em Juízo, a testemunha JOÃO GUILHERME RIBEIRO afirmou que: o local é conhecido por tráfico de drogas; fizeram uma incursão (com Cabo Amaral); as outras duas viaturas foram para outras ruas; a viatura da testemunha com AMARAL entrou na rua; os Réus esboçaram uma reação duvidosa; AMARAL abordou JURACI, sendo encontrados 22 pinos de cocaína; BRUNO tentou se evadir; conseguiu abordar BRUNO, que estava com 2 pinos de cocaína e cerca de R\$200,00 em notas pequenas; BRUNO falou que o dinheiro era produto da venda da droga; JURACI falou que pegou a droga com JOHN JOHN, que não conhece, e que iria vender; os Réus foram encaminhados à delegacia de polícia; o local é conhecido como biqueira; os Réus estavam caminhando próximos um do outro; não conhecia nenhum dos dois; os Réus não aparentavam ter feito uso de drogas; BRUNO tentou se evadir e JURACI ficou estático; não aparentavam ter usado cocaína; BRUNO falou que o dinheiro era resultante da venda de alguns pinos de cocaína; os dois foram encontrados com drogas semelhantes (pinos amarelos com cocaína); nunca tinha visto BRUNO naquela região; JURACI falou que pegou as drogas e iria vender na Chácara do Moinho; não viu ninguém ser apreendido com drogas vendidas por JURACI; não viu ninguém comprando entorpecente de nenhum dos dois; acredita que os dois estarem lá foi circunstancial; não houve passagem de drogas de um para outro; só GUILHERME e AMARAL fizeram abordagem aos Réus.

Ouvida em Juízo, a testemunha MARCO ANTONIO DO AMARAL afirmou que: estavam em patrulha pelo bairro da Vila Carmen; ao entrar na travessa em questão, conhecida por tráfico de drogas, viram uns indivíduos que mostraram nervosismo ao verem a polícia; abordou JURACI; o companheiro conseguiu abordar BRUNO; quando foram submetidos à busca pessoal, encontraram 22 pinos com JURACI em sua cueca; com BRUNO, foram encontrados 2 pinos da mesma forma e cerca de R\$220 a R\$230,00 reais; BRUNO relatou que o dinheiro viria da venda; JURACI relatou que havia pego com JHONJHON a droga para comercializar na chácara do moinho e que praticava o tráfico ali há umas 2 semanas; deram voz de prisão e conduziram à delegacia; lembra com clareza dos fatos ocorridos na noite; BRUNO disse que estava desde às 19h vendendo drogas no local; na delegacia, BRUNO relatou que estava no ponto e que para tomar cuidado com o policial AMARAL, mesmo sem conhecê-lo; não informou o fato de estarem desde às 19h na delegacia; os dois tentaram correr quando foram avistados; conseguiu abordar JURACI imediatamente; BRUNO tentou se evadir, mas o companheiro conseguiu abordá-los; os Réus não falaram que estavam vendendo jogar juntos; JURACI falou que tinha ido buscar drogas para traficar em outro lugar (Chácara do Moinho); BRUNO falou que estava vendendo drogas no local.

Em seu interrogatório, o Réu BRUNO ANTUNES ORTIZ afirmou que: nega os fatos; estava com as drogas, mas para uso próprio; trabalhava de servente, de segunda a sexta; toda semana, recebia R\$350,00 do trabalho; tinha passado em uma clínica de recuperação em Cachoeira Paulista; marcou com os amigos e foi para Cachoeira; na praça, começou a beber; costuma beber para cheirar; deu vontade de cheirar; perguntou para a turma o local que tinha cocaína para vender; foi para o local; pegou 2 pinos com a menina; no que foi sair, a polícia falou que era traficante; trabalhava de servente com um colega que mora perto da casa, de nome PEDRO; trabalhava numa casa, fazendo o segundo andar da casa; não tem passagem por roubo,

só como usuário; não tem envolvimento em processo de Roseira; nunca esteve em Roseira; não conhece JURACI; não confessou nada; se sentiu coagido na delegacia pelos policiais.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato.

(TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos foram coerentes entre si, convergindo quanto aos seguintes fatos: a) os Réus foram abordados em via pública; b) com BRUNO, foram encontrados

R\$221,00 em espécie e 2 pinos de cocaína; c) com JURACI, foram encontrados 22 pinos de cocaína e ele estava saindo da biqueira.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria – Pena-base fundamentadamente exasperada – Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

Ao contrário do argumentado pela defesa técnica, não é viável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

O TJSP tem precedentes no sentido de que não deve haver a desclassificação quando as circunstâncias da conduta indicarem que o agente, surpreendido em posse de drogas, fazia-o para uso próprio:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500579-91.2021.8.26.0597; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Parcial razão. Materialidade e autoria

induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 4,72g (quatro gramas e setenta e dois centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, com peso bruto de 500,06g (quinhentos gramas e seis centigramas). Prova oral robusta. Inviabilidade de desclassificação para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendida não ultrapassa a normalidade à espécie, devendo manter-se o aumento da basilar apenas com relação aos maus antecedentes, na fração de 1/6 (um sexto). Comprovada reincidência. Impossível a concessão do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500181-14.2021.8.26.0123; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da defesa - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante - Suposto usuário de drogas admitiu na fase inquérito que o acusado lhe vendeu parte da droga apreendida - Desclassificação para o artigo 28 da Lei Drogas - Impossibilidade - Contexto fático não sugere que a droga seria para o consumo do acusado, mesmo porque 4 porções de cocaína foram apreendidas na posse de terceiro, após o acusado tê-las vendido - Presentes os requisitos do "privilégio" (§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas), deve a diminuição de pena ser feita na fração máxima (2/3) - Inviabilidade de se operar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como modificar o regime semiaberto, porquanto, no curso desta ação penal, o acusado foi condenado outras duas vezes pelo mesmo crime - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1501281-78.2020.8.26.0530; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

Com relação a BRUNO ANTUNES ORTIZ, os seguintes elementos indicam que a sua conduta não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas: a) ele foi encontrado com significativa quantidade de dinheiro em notas miúdas, conforme auto de exibição de fl. 11 e depoimento dos policiais, o que é indício do comércio no local; b) apesar de afirmar que trabalhava de servente (o que justificaria a quantia), não trouxe nenhuma prova da prestação do serviço nem do recebimento dos valores naquela data; c) os policiais relataram que os Réus não aparentavam estar sob o efeito de drogas; d) em seu interrogatório, além de indicar que exercia atividade lícita, o Réu negou que tivesse qualquer passagem por Roseira, o que é contrariado pela certidão de fl. 54 (proc. n. 1500345-08.2019.8.26.0621) e põe dúvidas sobre a credibilidade das informações prestadas.

Quanto a JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, o fato de terem sido encontrados 22 pinos de cocaína em sua cueca, enrolados num plástico, confirmam que tal quantidade de drogas vai além do consumo próprio e tinha outra destinação.

Por isso, é inviável a desclassificação pretendida.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que os Réus BRUNO ANTUNES ORTIZ e JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticaram os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, os réus sequer alegaram a existência de causas

excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que os Réus sequer suscitaram a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que os Réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação dos Réus BRUNO ANTUNES ORTIZ e JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Da dosimetria de BRUNO ANTUNES ORTIZ

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: tratam-se de acusados sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: visando não incidir em bis in idem serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria.

Assim, diante da ausência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a reconhecer, razão pela qual a pena-intermediária é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que pressupõe que “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

O STJ entende que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, sem que isso represente violação à presunção de inocência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de

inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

- A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, a forma como se deu a prisão em flagrante (precedida de investigação pela prática de outro delito que resultou em mandado judicial de busca e apreensão domiciliar), a quantidade e a forma de acomodação do material entorpecente apreendido e o fato de o agravante responder a outras ações penais sugerem a sua dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 684.376/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifos acrescidos)

Já o STF tem precedentes em sentido contrário:

PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) (grifos acrescidos)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) (grifos acrescidos)

Como ponto de partida, entendo que, em princípio, inquéritos e ações penais em curso não podem afastar a causa de diminuição de pena.

Por outro lado, há situações em que se pode verificar, mesmo sem o trânsito em julgado, que há dedicação a atividades criminosas: a) prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo; b) sentença condenatória proferida em outro processo.

No caso concreto, não há prova de nenhuma das hipóteses acima (a movimentação do processo de n. 1500345-08.2019.8.26.0621 (fl. 54) não apresenta andamento desde 2019), de sorte que entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Considerando a apreensão de droga da espécie cocaína, a pena intermediária deve ser

diminuída na fração de 1/2, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP), e a prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Da dosimetria de JURACI RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: tratam-se de acusados sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: visando não incidir em bis in idem serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria.

Assim, diante da ausência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a reconhecer, razão pela qual a pena-intermediária é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que pressupõe que “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

O STJ entende que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, sem que isso represente violação à presunção de inocência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre

organização criminosa.

- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

- A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, a forma como se deu a prisão em flagrante (precedida de investigação pela prática de outro delito que resultou em mandado judicial de busca e apreensão domiciliar), a quantidade e a forma de acomodação do material entorpecente apreendido e o fato de o agravante responder a outras ações penais sugerem a sua dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 684.376/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifos acrescidos)

Já o STF tem precedentes em sentido contrário:

PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) (grifos acrescidos)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) (grifos acrescidos)

Como ponto de partida, entendo que, em princípio, inquéritos e ações penais em curso não podem afastar a causa de diminuição de pena.

Por outro lado, há situações em que se pode verificar, mesmo sem o trânsito em julgado, que há dedicação a atividades criminosas: a) prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo; b) sentença condenatória proferida em outro processo.

No caso concreto, não há prova de nenhuma das hipóteses acima (não houve sentença no processo de n. 1500489-84.2019.8.26.0102 e o Réu foi absolvido no processo de n.

1500583-27.2019.8.26.0102 - fls. 58/59), de sorte que entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Considerando a apreensão de droga da espécie cocaína, a pena intermediária deve ser diminuída na fração de 1/2, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Impede salientar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP), e a prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP).

Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

II.2 Do crime do art. 35 da Lei de Drogas

No caso concreto, não há prova suficiente para a condenação, como reconhecido pelo MP em suas alegações finais.

Como se sabe, a condenação criminal exige um grau muito elevado de probabilidade quanto às alegações de fato, a ponto de haver o dever de absolver quando não há provas ou quando existe uma dúvida razoável em favor do acusado:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

(Redação dada